



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000890539

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006095-08.2011.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante DAVID CEZAR DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para: (i) reduzir a pena do apelante para 3 (três) meses de detenção; (ii) afastar a prestação de serviços à comunidade fixada como condição imposta cumulativamente ao cumprimento da pena em regime aberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos fundamentos. Comunique-se incontinenti.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e DE PAULA SANTOS.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

Moreira da Silva
Relator
(assinatura eletrônica)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO Nº 0006095-08.2011.8.26.0666

APELANTE: DAVID CEZAR DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: ARTUR NOGUEIRA

VOTO Nº 25.275

EMENTA: Apelação criminal – Lesão corporal no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Penas reduzidas – Pena-base que deve retornar ao patamar mínimo, eis que a conduta praticada não extrapola os limites do tipo penal - Regime prisional (aberto) escorreitamente fixado – Incabível, a espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o *sursis* – Afastamento da prestação de serviços à comunidade fixada como condição especial ao cumprimento ao regime aberto – Súmula nº 493 do Superior Tribunal de Justiça – Tese fixada em sede de recursos repetitivos - Recurso parcialmente provido.

1. Ao relatório da r. sentença monocrática acrescenta-se que David Cesar de Lima, por infração ao artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, sendo fixada a prestação de serviços à comunidade, desde logo, como condição especial para o cumprimento da pena em referido regime.

Inconformado, recorre. Acenando com a fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Regularmente processado o recurso, opina a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.

É o relatório.

2. O recurso comporta parcial provimento.

A materialidade do delito apresenta-se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), senão também e especialmente pelo laudo médico (fls. 7), que atestou a existência de lesão de natureza leve.

A autoria, por igual, emerge bem elucidada.

Na delegacia, o apelante negou os fatos, dizendo que, por ciúmes, a vítima começou a discutir com ele, devido a mensagens que ela viu em seu celular; então, Cássia passou a agredi-lo com “unhadas” em seu rosto. Com intuito de que ela parasse com “aquilo”, ele a segurou, empurrando-a, mas não houve agressão física (fls. 11).

Em Juízo, David esclareceu que houve agressões, porém, foram mútuas. Disse que foi o primeiro a ofender a vítima com palavras, ocasião em que ela “partiu pra cima”, com tapas e “unhadas”. Ressaltou que somente quis defender-se e, então, puxou os cabelos da vítima. Afirmou que desferiu um tapa em Cássia, mas não houve outras agressões. Acrescentou que ainda são sócios em uma empresa e que nunca mais tiveram problemas de relacionamento (mídia



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

audiovisual).

Malgrado a versão exculpatória, a prova produzida nos autos lhe é adversa.

Assim é que a vítima Cássia Elaine, ouvida na delegacia de polícia, informou que foi namorada de David durante três anos. Tinham rompido o relacionamento, porém mantinham contato, eis que eram sócios em uma empresa. Relatou que David tinha ido até a sua residência para entregar-lhe uma chave. Como estava no banheiro, ele aproveitou-se de sua ausência e passou a vasculhar seu celular, quando viu uma ligação de um desconhecido. Ele perguntou de quem era o número, mas ela não soube dizer; então, David começou a agredi-la com tapas no rosto, enforcou-a, puxou seus cabelos, jogou-a na cama e passou a ligar para o número desconhecido do celular. Acrescentou que vinha sendo agredida física e verbalmente pelo namorado havia, aproximadamente, um ano (fls. 06).

Em Juízo, Cássia reiterou a versão apresentada na delegacia, esclarecendo que ele passou a agredi-la depois que viu ligações de números desconhecidos em seu celular. Asseverou que as agressões sofridas por ela, no dia dos fatos, foram tapas na cara, puxões de cabelo e enforcamento. Disse que chegou a passar no pronto-socorro, a fim de atestar as lesões. Ressaltou que, depois desse fato, voltou a se relacionar com ele, porém as agressões continuaram; então, ela terminou definitivamente o namoro com David, mas mantém a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sociedade da empresa com ele. Contou que existem outros boletins de ocorrência, inclusive com pedidos de medida protetiva, que não “viraram nada” (mídia audiovisual).

Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, é assaz valiosa e importante na elucidação dos fatos, mormente porque, no mais das vezes, o crime é perpetrado longe do olhar de testemunhas, mas especialmente em caso como o deste processo penal, em que confortada por outros elementos probantes.

Inexiste nos autos demonstração de que o réu apenas tenha buscado defender-se ou de que tenha experimentado alguma lesão, revelando-se de todo inconvincente a sua versão exculpatória.

Desse quadro probatório, emerge a conclusão segura de que o apelante efetivamente ofendeu injustamente a integridade física de sua ex-namorada; seja porque o laudo médico, juntado às fls. 07, concluiu que a vítima sofreu lesão de natureza leve compatível com a dinâmica narrada nos autos; seja porque a vítima trouxe para os autos relatos sérios e convincentes.

Por outro vértice, o fato de o casal ter mantido relacionamento após a ocorrência dos fatos, conforme o depoimento prestado pela vítima (mídia audiovisual), não tem o condão de excluir a culpabilidade ou isentar o agente de pena, nem tampouco representa



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

renúncia da ofendida, máxime tendo em vista, quanto a esta última hipótese, que a natureza da ação penal é pública incondicionada.

Nesse sentido tem decidido esta Colenda Corte de Justiça:

“LESÃO CORPORAL Reconciliação do casal. Irrelevância. Revelia. Havendo vários boletins de ocorrência relatando a agressão e a desnecessidade de representação. O fato de harmonia posterior entre vítima e agressor não possui o condão de extinguir a pena. Agressões comprovadas. Prova testemunhal que comprova as agressões. Vontade da vítima quanto a não condenação ou a volta da harmonia do lar não interferem na lei penal diante do maior protecionismo que a lei específica quis dar coibindo os atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dosimetria da pena. Redução da pena base. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”¹

Destarte, porque suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável descrita na incoativa, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui

¹ - Apelação Criminal nº 0000084-80.2012.8.26.0648, Relator: Des. Rui Alberto Leme Cavalheiro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 28.07.2015.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

adotadas, exceto no tocante à pena.

Esta comporta reparo.

Na primeira etapa, a pena-base foi elevada pelo MM. Juiz sentenciante, mas deve voltar à mínima cominada no tipo penal. Sim, porque as circunstâncias da agressão confundem-se os elementos do próprio tipo penal vulnerado. E mais, não se há de falar em personalidade e conduta social ao argumento de que as agressões continuaram, já que tal circunstância deve ser demonstrada na seara própria à guisa de novos crimes, com a correspondente punição.

Ausentes demais circunstâncias modificativas, a pena resta definitivamente fixada em 3 (três) meses de detenção.

Vale anotar, ainda, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal, considerando que o crime foi praticado com violência contra pessoa (art. 44, I, CP).

Outrossim, o MM. Juiz *a quo* escorreitamente afastou a concessão do *sursis*, mormente em se considerando a gravidade do comportamento do acusado, que agrediu a ex-namorada com enforcamento, tapas, empurrões e puxões de cabelo.

Por fim, o eminente Magistrado sentenciante determinou o regime aberto e fixou a prestação de serviços à comunidade como condição especial ao cumprimento da pena em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

referido regime, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal.

Todavia, é sabido e consabido que as condições especiais expressas no dispositivo legal citado não se confundem com a pena legalmente prevista pela legislação penal.

Em outras palavras, é defeso ao Juiz estabelecer como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto, aquela já classificada como pena substitutiva (art. 44 do CP), vez que ocorreria o indesejável *bis in idem*, importando na aplicação de dúplice sanção.

Tal entendimento majoritário foi consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não somente pela Súmula nº 493, como também em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 20):

“Súmula 493: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.”

Confiram-se, ainda, outros julgados acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REGIME ABERTO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 115 DA LEP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. É lícito ao Juiz estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, em complementação daquelas previstas na LEP (art. 115 da LEP), mas não poderá adotar a esse título nenhum efeito já classificado como pena substitutiva (art. 44 do CPB), porque aí ocorreria o indesejável bis in idem, importando na aplicação de dúplici sanção.

2. Recurso Especial desprovido.”²

Nesse sentido, não se afasta o entendimento desta Colenda Câmara de Direito Criminal:

“APELAÇÃO – Uso de documento falso, para abertura de conta perante instituição financeira – Cédula de Identidade (RG) – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal – Absolvição ou desclassificação inviáveis – Ilícitude configurada – Condenação mantida – Substituição da pena prisional por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Imposição pelo Juízo, também, ao estabelecer o regime inicial aberto, de condição especial cumulativa, consistente na entrega de uma lata de leite por mês de pena – Impossibilidade – Fixação, em última

2 - STJ - REsp 1107314/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 05/10/2011.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

análise, de três sanções restritivas de direitos, em desacordo com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal – Bis in idem – Inviabilidade da referida condição especial, ademais, mesmo na hipótese de que se referisse unicamente ao caso de reconversão em sanção privativa de liberdade, nos termos da Súmula nº 493 do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido, apenas para afastar tal condição adicional (entrega de uma lata de leite por mês de pena). ”³

Dessa forma, de rigor, o afastamento da prestação de serviços à comunidade, como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto.

3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para: (i) reduzir a pena do apelante para 3 (três) meses de detenção; (ii) afastar a prestação de serviços à comunidade fixada como condição imposta cumulativamente ao cumprimento da pena em regime aberto, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença monocrática, por seus jurídicos fundamentos. Comunique-se *incontinenti*.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

³ - Apelação 0013528-29.2014.8.26.0320; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2016; Data de Registro: 29/08/2016.